壹、沿革及爭议

一、大清民律草案第二章家制、民国4年民律親屬編草案、民国14年民律草案親屬編均有規定

二、民國17親屬法草案刪除→純個人主义

三、19~設專章規定家制

四、重家長义務輕其权利（权利僅§1128 1條）→与古代之家有天壤之別（戴、林）

五、立法理由依Swiss採實質主义，但TW過於簡陋→无發揮空間，係空中樓閣，无切實基礎（戴、林、胡）

↳林、胡：瑞士家制之餘唾、我國家制之殘骸→家之存在可能无必要性

貳、定义

一、立法主义

1、JP：形式主义→戶籍同一即屬之

2、Swiss：實質主义→不問戶籍，為經營永久共同生活之親屬团体謂之家（TW→§1122）

二、要件：永久同居一家→通：永久同居之意思及事實缺一不可

三、出生之嬰兒→无意思能力，无同居意思但仍為家之構成員

四、22院848：兄弟业已分家，雖同門居住仍非一家

五、同居不以共財為必要

六、家暴§3家庭成員較廣，民法較狹

參、家長（§1123 I 家置家長）

一、§1125本文 家務由家長管理

二、推定（§1124前）：非法律之推定制，係由家之成員共同推選，可依選举或契約

1、史、趙：非親屬人員无推選及被推選之資格

2、戴、楨、林、許澍林：§1123 III 亦有非親屬以永久共同生活為目的同居一家，視為家屬，自有推举及被推举权

3、35院解3160、史、林：受推定人不論輩分、年齡、性別、婚生、養生

4、行為能力

(1) 有意思能力即可說（楨、高鳳仙）：推定後尚可指定家長

(2) 完全行為能力說（戴、史、林）：管理家務涉財產之管理、使用、收益、处分

三、法定：无推定或无法推定→§1124中、後：最尊輩；輩分同以年長者為之

↳最尊輩无完全行為能力→次尊輩且有行為能力最年長者（夫妻、兄弟以年長者任之）（胡、史、楨、林）

四、指定：法定家長不願或不能管理家務→指定家屬一人代理之（§1124末）

1、代理：非一般代理→非以法定家長名义管理，亦不受其指揮、約束，不因其死亡喪失权限

2、另推他人、另指定他人為家長，則指定家長免其职務（戴、史、楨、林）

肆、家屬 (§1123Ⅱ、Ⅲ)

一、§1123Ⅱ：除家長外，均為家屬

二、§1123Ⅲ：非親屬以永久共同生活為目的同居一家，視為家屬

三、夫妻非親屬，但係以永久共同生活為目的同居一家，視為家屬

四、妾非親屬，但係以永久共同生活為目的同居一家，視為家屬 (21院735)

五、父死子繼任家長，父之妾仍屬家屬 (SC 21上2238例)

六、父母與子女之未婚配偶共同生活，亦為家屬 (22院959、SC 23上3096例)

七、長工、傭人、學徒應視時間判斷是否係家屬

伍、家務之管理

一、§1125本文 家務由家長管理 ⇒ 家財之管理屬家長 (ex：父死因清償之必要，得就遺產設定負擔) (SC 33上576例、1196例)

二、对內义務重於权利

三、處分家屬私有財產，應得其同意

四、§1126：家長管理家務應注意家屬全體利益 ⇒ 注意程度？

1、具体輕過失說 (史尚寬、鼎、胡)：Swizz §332Ⅲ、舊§1100

2、抽象輕過失說 (棋、戴、許澍林、林)：Swizz學說、新§1110

陸、分離

一、基於家屬請求 (§1127)

1、无完全行為能力无請求权 (SC 32上5876例、31上1494例)

2、妻有同居义務，不得請求分離 (SC 29渝上527例)

3、妻无同居义務，得請求分離 (28院1935、SC 20上1437例、33上5119例)

4、係形成权，非請求权 ⇒ 无須同意 (戴、林、棋、史、高鳳仙；反对：鼎)

二、基於家長命令 (§1128)

1、§1128但：以有正当理由為限 ⇒ 防止家長濫用权力 (20院560)

2、正当理由：具体定之，不可一概而論 (ex：行為不檢、有辱家声、多端為惡、遺害門楣) (SC 29渝上2008例、26上544例、屏東地院108家声14裁)

3、家長依§1128令分離无給付一定財產之必要 (SC 33上464例)

↳ 親屬身分仍不消失 ⇒ 仍有扶養請求权 (SC 21上2160例)